

1500148-98.2021.8.26.0551

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ricardo Truite Alves

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/01/2022

... mercantil da posse e da guarda da droga como tráfico consumado. O mero fato de o agente guardar ou ter em depósito drogas, ainda que a mando de terceiros, mesmo que sem intuito de lucro, configura o crime de tráfico de drogas, pois o tipo penal prevê como tráfico as condutas de guardar e ter em depósito, ainda que gratuitamente (art. 33, caput, Lei de Drogas). ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

2ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500148-98.2021.8.26.0551 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500148-98.2021.8.26.0551

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2090631/2021 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 17131739 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO,

810/21/923 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2090631 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA, 810/21/923 -

DISE- DEL.SEC.LIMEIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FELIPE HENRIQUE JUSTINO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ricardo Truite Alves

Vistos.

FELIPE HENRIQUE JUSTINO, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "j" (calamidade pública), do Código Penal.

Consta do incluso inquérito policial que, em 03 de abril de 2021, por volta das 22h40min, na Rua Waldemar Panaro, nº 150, Jardim São Paulo, nesta cidade e comarca de Limeira, durante estado de calamidade pública, decorrente da pandemia do COVID-19 (cf. Decreto Estadual n. 64879 de 20.03.2020, publicado no DOE-SP de 21.03.2021), o acusado, em atividade de tráfico ilícito, trazia consigo e transportava, para serem entregues a consumo de terceiros, 01 (uma) porção de cocaína à granel, pesando aproximadamente 87g (oitenta e sete gramas), e 01 (uma)

porção de maconha, com peso aproximado de 3g (três gramas), além de 01 (uma) grande porção de cafeína, pesando cerca de 200g (duzentos gramas), matéria-prima destinada à preparação de drogas, assim agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (cf. auto de exibição e apreensão, fotografias, laudo de constatação e laudo de exame toxicológico).

Ao que se apurou, durante estado de calamidade pública decorrente da pandemia do COVID-19, na ocasião supramencionada, o acusado trazia consigo e transportava, na via pública, drogas e matéria-prima destinada à preparação de drogas.

Ocorre que, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina pelo sítio do evento quando avistaram o acusado na condução do veículo Corsa, de placas DDN-3830, o qual não obedeceu a ordem de parada emanada e evadiu-se, arremessando do interior do veículo, no trajeto da fuga, uma bolsa. Ato contínuo, após breve perseguição, logrou-se na abordagem.

Em revista pessoal, com o acusado foi encontrada 01 (uma) porção de maconha, a qual trazia consigo para ser entregue ao consumo de terceiros, bem como quatro flaconetes vazios e a quantia de R\$198,00 (cento e noventa e oito reais), obtida com o narcotráfico.

Em seguida, vistoriada a bolsa dispensado pelo acusado no trajeto da fuga, os agentes públicos encontraram, em seu interior, 01 (uma) grande porção de cocaína à granel, drogas que transportava para serem destinadas à traficância, além de 01 (uma) grande porção de cafeína, matéria-prima que seria destinada à preparação de drogas.

Ainda no interior da aludida bolsa, os policiais encontraram dois mil flaconetes, semelhantes àqueles que o acusado trazia consigo, apetrechos comumente utilizados para individualização e distribuição de entorpecentes.

Oferecida à denúncia, determinou-se a notificação do réu para que apresentasse defesa preliminar, que veio aos autos (fls. 152/165).

A denúncia foi recebida em 22 de março de 2021 (fls. 169/170).

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas e o réu, interrogado ao final (mídia).

Encerrada a instrução, as partes manifestaram-se.

O Ministério Público e a Defesa ofereceram memoriais escritos (fls. 215/220 e 222/223).

É o breve relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Não há preliminares pendentes de apreciação.

O pedido condenatório é procedente.

A materialidade restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 05), boletim de ocorrência (17/20) auto de exibição e apreensão (fls. 21/22), laudo pericial com resultado positivo para “cocaína” e “maconha” (fls. 30/33, 34/36 e 122/124), bem como pela prova oral colhida no curso da persecução penal.

A autoria é certa.

Perante a Autoridade Policial, o acusado negou os fatos que lhe são imputados. Disse que não obedeceu ao sinal de parada porque não é habilitado. Em sua carteira tinha uma porção de maconha para consumo próprio e quatro pinos vazios de cocaína, que consumiu anteriormente, bem como dinheiro fruto de seu trabalho. Nada arremessou para fora do veículo. Negou estar transportando drogas em seu veículo (fls. 09).

Em Juízo, o réu disse que tem 24 anos. Trabalha na Pralana chapéus há três anos e seis meses. Tinha carteira assinada, como inspetor de produtos. Contou que estava na casa de Patrick, seu amigo. Iriam passar na casa de Eduardo, mas este não quis sair. Estava perto de um bairro, foram lá e tudo estava fechado. Na rotatória a viatura veio atrás e mandou parar. Ficou com medo por estar sem CNH. Acelerou por desespero. Iria pra sua casa. Foi abordado por uma viatura, parou o carro. Falou que não tinha habilitação. Pediu desculpas. Foi levado ao Distrito Policial. Não jogou qualquer bolsa pela janela. Patrick falou que não tinha bolsa. Foi preso injustamente. Não vai assumir o que não fez. O dinheiro da carteira é do seu trabalho. Havia um pino do grande e uma bucha na sua carteira. Fazia uso de drogas e nunca vendeu. Não havia flaconetes vazios na sua carteira. Não falou na Delegacia que tinha quatro pinos vazios, mas apenas um. Não atropelou pessoas. Não jogou o carro na viatura, mas estava a 80 km/h. Ficou com medo de sofrer enquadro. Não leu o depoimento na Delegacia, não tinha advogado no dia. Faz uso de maconha e cocaína. Não chegou a ver a bolsa, na Delegacia havia dois pacotes de pinos vazios. Ganha por mês em torno de mil oitocentos e cinquenta reais. Não tem filhos. Mora com seus pais e irmãos. Era sua mãe que financiou o veículo, ajudava ela a pagar (mídia).

Sua versão não convence.

Vejamos o teor da prova oral.

O policial militar João Paulo Manarin Antonieto disse que na noite da abordagem faziam patrulhamento de rotina. Viram o veículo andando em certa velocidade. Deram sinal de abordagem, sem sucesso. Houve fuga. Quando ele percebeu a aproximação da viatura, pelo lado do motorista foi arremessado uma bolsa preta. Por várias vezes o motorista jogou o carro em cima da viatura. Isso permaneceu por longo período. Ele sempre fechava o veículo em cima deles. Conseguiram aborda-lo em local que já havia várias viaturas. Fizeram abordagem. Com o passageiro nada foi localizado. Com o condutor do veículo (acusado) havia quatro flaconetes de cocaína, dinheiro e uma bucha de maconha. Avisou a guarnição que havia sido dispensado uma bolsa preta. A viatura se deslocou e encontrou a bolsa preta. Viram que na bolsa havia um pacote com pó branco, um pote com pó branco e flaconetes vazios. Acionaram o guincho. Foram ao Plantão Policial. Conversou com o passageiro Patrick e este disse que todos os objetos encontrados eram do denunciado. A dispensa da bolsa foi pelo lado do motorista. Não conhecia o réu e nem o passageiro. Não teve contato com o imputado, falou mais com Patrick. Ouviu o acusado falando que havia errado dessa vez. Os flaconetes encontrados na carteira eram idênticos aos da bolsa. Acompanhou o flagrante na Delegacia, mas não teve tanto diálogo com o réu (mídia).

O policial militar Renato de Souza Andrade contou que faziam patrulhamento de rotina quando viram o automóvel. Deram ordem de parada, mas houve fuga. Na altura da rotatória, houve dispensa de uma bolsa preta. Deram continuação ao acompanhamento. O réu fazia manobras perigosas, ele tentava jogar o veículo contra a viatura policial. Tiveram apoio de outras viaturas. Conseguiram fazer abordagem na altura do bairro Cecap. Havia duas pessoas no automóvel. Em busca pessoal seu parceiro encontrou drogas e dinheiro com o acusado. Diante dos fatos, solicitaram apoio de viaturas que fizeram o caminho de volta. A bolsa foi localizada. Apresentaram a ocorrência no plantão policial. Visualizou a dispensa da bolsa pelo lado do motorista, que era o réu. Localizaram droga e dinheiro com o acusado. Foi o seu parceiro que fez a busca pessoal. Indagado, o réu disse que tinha medo da abordagem, por isso ele fugiu. O réu confirmou informalmente a propriedade da droga

dispensada. Não o conhecia até então. Não se recorda o que o passageiro disse. Não se recorda o estado do acusado. Não se lembra se a documentação estava vencida. Não sabe o destino do automóvel (mídia).

Foram arroladas testemunhas de Defesa.

A testemunha Jeferson Rodrigo Sobral disse que é amigo de infância do acusado. Sabe que ele sempre trabalhou e nunca se envolveu com problemas. O acusado trabalhava registrado, mas não sabe o valor do salário. Ficou surpreso com a situação do acusado. Não presenciou os fatos (mídia).

A testemunha Alberto dos Anjos Pereira contou que é cunhado do acusado. Mencionou que o réu é boa pessoa e é trabalhador. Desconhecia o envolvimento dele com o tráfico, inclusive não sabia que ele fazia uso de drogas. Sabe que o réu trabalhava registrado. Desconhece a documentação do veículo (mídia).

Pois bem.

Pelo que se verifica da prova oral colhida, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina quando avistaram o veículo Corsa, o qual não obedeceu ao sinal de parada e evadiu-se, arremessando uma bolsa preta no trajeto da fuga. Ato contínuo, após breve perseguição, os policiais conseguiram abordar o motorista do veículo, identificado como FELIPE.

Em revista pessoal, foram apreendidos dentro da sua carteira a quantia de R\$198,00 em notas diversas, 04 quatro flaconetes vazios e uma pequena bucha de maconha pesando 05 gramas. Na bolsa que FELIPE arremessou no trajeto da fuga, foram localizadas 01 (uma) grande porção de cocaína à granel, drogas que transportava para serem destinadas à traficância, além de 01 (uma) grande porção de cafeína, matéria-prima que seria destinada à preparação de drogas.

Assim, o conjunto probatório é harmônico, robusto e conclusivo quanto à materialidade e à autoria do crime de tráfico imputado, haja vista a quantidade, a natureza, a diversidade e a forma como estavam embaladas as drogas (cocaína e maconha), as circunstâncias da prisão em flagrante e o depoimento incriminador dos policiais militares, tudo a apontar o réu como sendo pessoa envolvida no tráfico de drogas.

Sobre o tema em comento, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo é remansosa:

"APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico ilícito de drogas - Artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006 - Absolvição ou, ainda, desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 28 da Lei de Drogas - Descabimento - Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Palavra dos policiais militares - Credibilidade - Precedentes - Destinação mercantilista do entorpecente apreendido evidenciada pelas circunstâncias fáticas da prisão - Ausência de visualização de atos de mercancia - Irrelevância - Tipo misto ou de conteúdo variado - Condenação mantida (...) ". (TJSP; Apelação 0004568-50.2015.8.26.0126; Relator (a): Silmar Fernandes; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Caraguatatuba - Vara Criminal; Data do Julgamento: 18/09/2017; Data de Registro: 11/10/2017).

"TRÁFICO DE ENTORPECENTES. (...) Materialidade e autoria delitiva comprovadas, sobretudo diante dos relatos seguros dos policiais militares que participaram da diligência. Escusa ofertada pelo réu isolada no quadro probatório. Impossibilidade de desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/06. Condenação mantida (...)". (TJSP; Apelação 0000137-25.2017.8.26.0571; Relator (a): Tristão Ribeiro; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itapetininga - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 01/03/2018; Data de Registro:

01/03/2018).

"APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - INOCORRÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA BEM DEMONSTRADA, EM RELAÇÃO AO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS - PALAVRAS DOS AGENTES DA LEI QUE MERECEM PRIMAZIA NA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO, INCONSISTENTE A NEGATIVA DE AUTORIA - CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, LOCAL DA ABORDAGEM, CONHECIDO PONTO DE VENDA DE ENTORPECENTES, MODO COMO OS ESTUPEFACIENTES ESTAVAM EMBALADOS, QUANTIDADE SIGNIFICATIVA E NATUREZA ALTAMENTE NOCIVA COMPATÍVEIS COM O TRÁFICO(...) (TJSP; Apelação 0002975-45.2014.8.26.0344; Relator (a): Ivana David; Órgão Julgador: 9ª Câmara Criminal Extraordinária; Foro de Marília - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 15/09/2017; Data de Registro: 26/09/2017).

Segundo entendimento do saudoso Luiz Flávio Gomes:

"Para se concluir pela prática do crime de tráfico, não basta, em princípio, a quantidade (ou qualidade) da droga apreendida. Deve-se atentar, ainda, para outros fatores, tais como o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, a conduta, a qualificação e os antecedentes do agente (art. 52, I)" (GOMES, Luiz Flávio e CUNHA. Rogério Sanches (Coordenadores). Legislação Criminal Especial. Volume 6. São Paulo: Editora RT, 2009).

A combativa Defesa aponta pequenas divergências e supostas contradições no relato dos agentes públicos para pretender a absolvição, mas sem sucesso, já que pequenos desencontros são comuns e revelam a espontaneidade dos seus relatos.

Observo que não foram arroladas testemunhas de defesa que pudessem corroborar a versão do acusado de não ter qualquer envolvimento com o delito de tráfico de drogas, eis que os testemunhos defensivos são relativos à vida familiar e profissional do denunciado, devendo prevalecer o relato dos policiais militares que faziam o patrulhamento preventivo e o prenderam em flagrante delito.

E não há que se falar em desclassificação do delito de tráfico de drogas para o crime previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, principalmente em razão da quantidade, diversidade e natureza das drogas apreendidas, das circunstâncias da prisão em flagrante, existindo depoimento incriminador dos policiais militares.

Na esteira dos ensinamentos de Cleber Masson:

"Os critérios mencionados devem ser aferidos conjuntamente. Apenas um deles, isoladamente, nem sempre conduzirá o intérprete a adotar a melhor solução. Perceba-se, por curial, que uma quantidade relativamente pequena de droga não indica, necessariamente, que o sujeito ativo a tem para consumo pessoal. Como se sabe, é cada dia mais incomum a existência de grandes depósitos de drogas. Os traficantes, justamente para dificultar a ação repressiva do Estado, têm preferido muitas vezes trabalhar com pequenas quantidades distribuídas entre várias "mulas" (MASSON, Cleber. Lei de Drogas: aspectos penais e processuais. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2019).

Não é diferente o posicionamento jurisprudencial:

"Tráfico de entorpecentes - Dolo de traficar - Desclassificação para porte de entorpecentes (art. 28 da Lei n. 11.343/06) - Descabimento Provado o dolo genérico de traficar, tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06, não cabe a desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/06, se for observado que as demais circunstâncias que cercaram a prisão do acusado dão conta da caracterização do tráfico de entorpecentes (...)" (TJSP; Apelação 0002093-84.2015.8.26.0300; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Jardinópolis - 2ª Vara; Data do Julgamento: 01/03/2018; Data de Registro: 06/03/2018).

"APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Apreensão de porções de "maconha", "crack" e cocaína. Sentença condenatória. Defesa requer a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente pretende a desclassificação para consumo pessoal, o reconhecimento da figura privilegiada, o abrandamento do regime prisional, a substituição da carcerária por restritivas de direitos e a inconstitucionalidade da pena de multa. Materialidade e autoria indúvidas. Réu preso em flagrante na posse de entorpecentes, na via pública, após delação anônima feita aos policiais. Quantidade e diversidade denotam a traficância.(...)".(TJSP; Apelação 0005361-26.2016.8.26.0361; Relator (a): Carlos Monnerat; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mogi das Cruzes - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/12/2017; Data de Registro: 19/12/2017).

E não se exige a existência do efetivo comércio para a configuração do crime do artigo 33, "caput", da Lei de Drogas. Basta a guarda, o transporte, o trazer consigo, ou a manutenção em depósito, com a finalidade de distribuição ou de entrega a terceiros para que o crime se consuma.

A lei penal pune a mera finalidade (intenção) mercantil da posse e da guarda da droga como tráfico consumado. O mero fato de o agente guardar ou ter em depósito drogas, ainda que a mando de terceiros, mesmo que sem intuito de lucro, configura o crime de tráfico de drogas, pois o tipo penal prevê como tráfico as condutas de guardar e ter em depósito, ainda que gratuitamente (art. 33, caput, Lei de Drogas).

Em se tratando de crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública, de modo que é condenável a simples possibilidade de distribuição, gratuita ou onerosa, do entorpecente.

Em comentários ao artigo 33 da Lei de Drogas, o saudoso Luiz Flávio Gomes preleciona:

"(...) Deve ser lembrado que algumas modalidades são permanentes, protraindo o seu momento consumativo no tempo e no espaço (p.ex., expor à venda, trazer consigo, manter em depósito, guardar etc.). A multiplicidade de condutas incriminadas parece inviabilizar a tentativa (...)" (GOMES, Luiz Flávio et al. Nova Lei de Drogas Comentada Artigo por Artigo: Lei 11.343/06 de 23.08.2006. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006).

É esse o caso dos autos.

Note-se que o acusado não tinha trabalho lícito e formal ao tempo dos fatos que lhe propiciasse a aquisição de toda aquela quantidade de entorpecente.

Por outro lado, não é caso de reconhecimento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j" (calamidade pública), do Código Penal. Não há provas de que o acusado tenha agido para se aproveitar da situação de calamidade pública causada pela pandemia do COVID-19. O crime foi cometido em circunstâncias normais, motivo pelo qual afasto o reconhecimento da agravante.

A respeito do assunto, cito os seguintes julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça afastando a incidência da agravante em questão:

"Na hipótese, a agravante do art. 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, em tese seria cabível em desfavor do paciente, em face da crise causada pela pandemia, de ordem, econômica, social e sanitária, já que o crime foi cometido na vigência do Decreto Legislativo 6/2020, de 20/03/2020. Todavia, a despeito da prática do crime em ocasião de calamidade pública e do desvalor, sem dúvida, da conduta do paciente, não é suficiente, a meu sentir, a existência do Decreto que reconheceu o estado de calamidade pública para incidência da aludida agravante, uma vez que é imprescindível a existência de situação concreta dando conta de que o paciente se

prevaleceu da pandemia para a prática da traficância, e isso não foi devidamente demonstrado na hipótese em análise. Ademais, como bem destacou o parecer ministerial às fls. 73, grifei "A despeito da maior censurabilidade da conduta praticada no período de calamidade pública, o referido evento, por si só, não é suficiente para atrair a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, "j", do Código Penal, sob pena de responsabilização objetiva do agente." Por essas razões, entendo que deve ser afastada a agravante genérica descrita no art. 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal(...)" (STJ, HC 632.019/SP, Rel. Ministro FÉLIX FISCHER, julgado em 10/02/2021).

"O crime em si não está diretamente relacionado a essa circunstância da calamidade pública em questão, situação diferente de quando um delito é praticado durante um incêndio, ou naufrágio ou inundação, por exemplo. Neste caso presente, configura-se a responsabilidade objetiva e qualquer delito praticado durante este período da pandemia teria a sua pena agravada na segunda fase" (STJ, HC 620.531/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, julgado em 03/02/2021).

Desse modo, demonstrada a procedência da imputação contra o acusado, não existindo justificativas para os seus atos, passo à dosimetria das penas a serem aplicadas.

Concernente ao crime de tráfico de drogas, as circunstâncias judiciais dos artigos 59, do Código Penal, e 42, da Lei nº 11.343/2006, são inteiramente favoráveis ao réu, devendo a pena-base partir do mínimo legal, isto é, 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. A natureza e quantidade de drogas apreendidas no caso em tela não justificam a exasperação da pena-base pois não se trata de quantidade elevada.

Não há agravantes. Por outro lado, deixo de aplicar qualquer atenuante, pois a pena-base já foi estabelecida no patamar mínimo, observando-se o teor da Súmula n. 231 do Colendo STJ.

Ausentes quaisquer causas de aumento.

Sendo o réu primário, de bons antecedentes e não havendo prova de que integra organização criminosa, aplico a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4ª, da Lei nº 11.343/2006, reduzindo a reprimenda em 1/2 (metade), tornando-se definitiva a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Para que fique bem claro, na derradeira etapa do sistema trifásico, deve ser levada em consideração a causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Tóxicos, causa esta que, uma vez verificados seus requisitos, deve ser aplicada.

A este respeito, deve ser acolhido o seguinte preceito doutrinário:

"Dispõe o parágrafo, em sua parte final, sobre condições negativas de que o agente não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Toda prova negativa é difícil, de modo que militará em favor do réu a presunção de que é primário e de bons antecedentes e de que não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa. O ônus da prova, no caso, é do Ministério Público no sentido de demonstrar a reincidência, os maus antecedentes e a participação em atividades criminosas ou organização criminosa. Não importa que a prova seja difícil para o Ministério Público. Mais difícil seria para o réu que, por sua vez, tem o direito de não ser condenado a não ser que haja prova, ou receber, sem prova, uma pena maior quando a lei permite uma pena mais branda" (GRECO FILHO, Vicente e RASSI, João Daniel. Lei de Drogas Anotada. São Paulo: Saraiva, 2008).

O valor do dia multa será no mínimo legal.

Considerando o posicionamento do Supremo Tribunal Federal no acórdão proferido no HC 118.553/MS, no sentido de que o delito de tráfico de drogas privilegiado não possui natureza hedionda, revejo meu entendimento para admitir a fixação de regime

inicial carcerário mais brando aos condenados pela prática daquela infração penal. De fato, o tráfico de entorpecentes privilegiado não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1º do art. 33 da Lei de Tóxicos. Dessa forma, fixo o regime inicial semiaberto para o caso em questão (apreensão de 01 porção de cocaína à granel, pesando aproximadamente 87 gramas, e 01 porção de maconha, com peso aproximado de 3 gramas).

Para a imposição de regime prisional mais gravoso do que a pena comporta, é necessária fundamentação específica, com base em elementos concretos extraídos dos autos, conforme Súmulas 440/STJ e 718 e 719 do Colendo STF, que assim dispõem: Súmula 440/STJ: Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito.

Súmula 718/STF: A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada.

Súmula 719/STF: A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.

No mais, diante do reconhecimento do tráfico privilegiado, aplica-se a Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime) na fixação do regime prisional, assim como as decisões dos Tribunais Superiores (STF e STJ).

Inadmissível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos por força da restrição imposta pelo art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, bem como pela suspensão condicional da pena em função da vedação do art. 44, da Lei nº 11.343/2006.

No entanto, a partir do julgamento do HC 97.256/RS pelo STF, declarando incidentalmente a parcial inconstitucionalidade do § 4º do art. 33 e do art. 44, ambos da Lei n. 11.343/2006, o benefício da substituição da pena passou a ser concedido aos condenados pelo crime de tráfico de drogas, desde que preenchidos os requisitos insertos no art. 44 do Código Penal.

Não basta a primariedade do acusado para fazer jus à substituição, pois deve o juiz levar em conta, além da natureza e da quantidade da substância ou do produto, a personalidade do agente e a conduta social do agente.

Nesses termos, entendo que o comportamento do réu em Juízo leva a crer que sua personalidade, no que tange à maturidade e a responsabilidade, torna inviável a conversão da pena em restritivas de direitos.

A medida alternativa não é suficiente em razão da falta de atendimento do pressuposto subjetivo previsto no artigo 44, inciso III, do CP, insuficiente para prevenção e repressão do tráfico (cf. STJ, HC 435.632/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 26/03/2018; HC 390.554/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 22/05/2017).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar FELIPE HENRIQUE JUSTINO, qualificado nos autos, às penas de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, além de pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no seu menor valor, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 c/c a redução prevista no §4º do art. 33 ambos da mesma lei.

Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade, se não estiver preso em razão de outro processo, por força do regime inicial fixado e do tempo de prisão processual, incompatível com a prisão preventiva. Expeça-se alvará de soltura.

A detração penal será analisada em sede de execução, devendo se verificar a conduta carcerária do réu e os demais requisitos do processo de execução.

Custas na forma da lei, observada a gratuidade processual ora concedida.

Defiro a incineração da substância entorpecente apreendida, com as cautelas de praxe, pela qual representou a autoridade policial.

Decreto o perdimento do dinheiro apreendido.

Após o trânsito em julgado, o nome do réu deverá ser lançado no rol dos culpados.

P.R.I.C.

Limeira, 07 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA